

1500583-55.2022.8.26.0222

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 2º Vara Judicial

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... - Voto nº 29898 - J 9 101/498).

"TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

2º Vara Judicial

Rua Feres Sadalla, Nº 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500583-55.2022.8.26.0222 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500583-55.2022.8.26.0222

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2113504/2022 - DEL.POL.GUARIBA, 24564714 -

DEL.POL.GUARIBA, 2113504 - DEL.POL.GUARIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALMIR ROSNER CAVALHEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou ALMIR ROSNER CAVALHEIRO como incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 27 de abril de 2022, por volta das 10h40, na Avenida Elias Gazon, 211, em Guariba/SP, trazia consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 15 porções de Cannabis Sativa L, 16 porções de cocaína e 16 porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia às fls. 113/117.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas de acusação, sendo o réu interrogado ao final.

As partes apresentaram memoriais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu. Na dosimetria, pediu a majoração da pena base acima do mínimo

legal, considerando a quantidade e espécie de drogas apreendidas.

A defesa do acusado postulou o reconhecimento das atenuantes da maioridade relativa, bem como o reconhecimento da causa de diminuição da pena pela pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, alegando ainda a ausência de maus antecedentes.

É o sucinto RELATÓRIO.

Passo à FUNDAMENTAÇÃO e DECIDO.

A materialidade do delito foi provada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 13/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 95/103), bem como pela prova oral colhida em audiência de instrução, debates e julgamento.

As testemunhas ouvidas em audiências, policiais militares que participaram da audiência, narraram que o réu foi abordado em patrulhamento de rotina em local sabidamente ponto de tráfico de entorpecentes, e que arremessou um pote ao avistar os policiais, o qual, recolhido, continha os entorpecentes apontados no boletim de ocorrência. O Policial Iranildo acrescentou ainda que quando da abordagem o réu disse que os entorpecentes eram para uso pessoal, reconhecendo a sua posse, bem como que o réu já era conhecido dos meios policiais por habitual prática de traficância.

O réu, em interrogatório, negou a prática da traficância ou mesmo a posse dos entorpecentes apreendidos. Disse que o policial Iranildo já havia lhe abordado anteriormente por várias vezes e sempre dizia que "ia acabar com a sua vida".

Pois bem. Eis o teor da prova oral produzida.

Ora, não se trata simplesmente de desmerecer a versão do acusado.

É que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Os policiais militares prestaram depoimentos seguros e coesos, sendo que, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

O simples fato de estas testemunhas pertencerem aos quadros da polícia e terem participado das diligências que culminaram com a prisão do acusado não os torna indignos de fé, sobretudo porque não há qualquer indício de que tenham prestado seus depoimentos com o fito de legitimar a conduta funcional, de cuja regularidade, aliás, não há razão para se duvidar.

Não há razão para a absolvição quando as únicas testemunhas de acusação são os próprios investigadores ou policiais militares que cuidaram do caso nas fases extrajudiciais, já que não existe qualquer impedimento nesta dupla atuação. Ora, a partir do momento em que o Estado legitimou a investidura da Polícia Civil e Militar no combate à criminalidade, pode e deve o Estado-juiz conceder-lhes o mesmo crédito inicialmente depositado quando narram suas atividades, já que cientes de seu compromisso de dizer a verdade, sujeitos às penas do crime de falso testemunho ou de denúncia caluniosa, exatamente como os demais cidadãos. Neste sentido:

"A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação" (TJSP, Apelação Criminal nº. 128.275-3/9 - Rel. Des. Canguçu de Almeida)"

Ressalto, ainda que eventual condição de usuário não afasta, por si só, a tipificação do tráfico de entorpecentes, sobretudo porque as circunstâncias do flagrante apontam de forma clara a destinação dos entorpecentes para a mercancia, ante a sua variedade, quantidade, local do flagrante, apreensão de quantia considerável de dinheiro em cédulas de pequeno valor.

E, por fim, o acondicionamento das drogas como feito quando da apreensão não se coaduna com a situação de quem pretendia consumi-las para saciar seu vício.

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente

na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJ TJ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 4ª Câmara de Direito Criminal Apelação nº 0000248-23.2016.8.26.0610 - Voto nº 29898 - J 9 101/498).

"TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admite várias condutas. Impossível a desqualificação de tráfico para o uso de entorpecente tendo em vista que o recorrente não comprovou, na fase instrutória, a destinação da droga para o uso pessoal, pelo contrário, ficaram evidenciados os atos de traficância pela quantidade e a forma em que a droga foi encontrada (vinte pedras de 'crack' e um pacote de cocaína). Mesmo que consideremos o fato do acusado ser usuário de 'crack' e cocaína, tal condição não afasta a qualificação de traficante, ocorrendo a absorção do delito de porte para uso pelo de tráfico." (Apelação Criminal Nº 1.0625.04.037027-6/001 - Comarca De São João Del-Rei. Relator: exmo. Sr. Des. Sérgio Braga.j.22.05.2005)"

De outra parte, ainda que os policiais não tenham presenciado o réu em atitude típica de traficância, tal circunstância não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal. Isso porque a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 consiste em um tipo misto alternativo e tem como um de seus núcleos "trazer consigo, ou guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, pelas circunstâncias, está claro o propósito de tráfico, tanto pela quantidade quanto pela forma de acondicionamento dos entorpecentes.

Noto, por fim, que as alegadas inconsistências nos relatos dos policiais, feita pela defesa, se tratam de pontos irrelevantes.

Colocadas tais ponderações, passo a dosar a pena.

Considerando as circunstâncias judiciais, conforme dispõe o artigo 42, da Lei n.º 11.343/06 combinado com o artigo 59, do Código Penal, verifico que a fixação da pena-base acima do mínimo legal é medida pertinente e necessária para a prevenção e repressão da prática criminosa em comento, tendo em vista que, entre os diversos entorpecentes apreendidos, encontra-se a cocaína em forma de crack, cujo combate merece especial enlevo ante o maior poder de vício que exerce entre os usuários, causando juntamente a fissura pelo consumo da droga que conduz a outras espécies de criminalidade e, conseqüentemente, a degeneração da família e da vida em sociedade. Com efeito, o artigo 42, da Lei n.º 11.343/06 determina que a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente sejam consideradas circunstâncias preponderantes sobre quaisquer outras previstas no artigo 59, do Código Penal, na primeira fase de dosimetria da pena. Outrossim, há conduta social desfavorável a ser considerada em razão da condenação posterior por fatos anteriores. Assim, fixo a pena base em 06 (seis) anos e de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, em seu valor mínimo unitário (fls. 42/43).

Na segunda fase, reconheço a atenuante da maioridade relativa (fls. 08). Assim, reduzo a pena em 1/6, totalizando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Não há causas de aumento da pena.

Os requisitos (cumulativos) para aplicação da causa de diminuição estão taxativamente previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06: ser a agente primário, detentor de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. O referido dispositivo prevê a possibilidade do Juiz (leia-se: poder-dever) em reduzir de 1/6 a 2/3 a pena fixada quando presentes os quatro requisitos cumulativos acima elencados, sem, contudo, estabelecer parâmetros para o exato estabelecimento deste quantum pelo magistrado. Falhou o legislador. Por tais razões compete a doutrina hodierna e a jurisprudência o interpretarem à luz das peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse diapasão é que, no caso em exame há de ser levada em conta a quantidade

substâncias apreendidas. Parece-me razoável asseverar que quanto maior a quantidade, mais variados os tipos e o campo de comercialização deles, menor a diminuição da pena. É nesse sentido, inclusive, o posicionamento da 5ª Turma do C. STJ (HC 136.618/MG, Min. Laurita Vaz, v.u. 01.06.10) e da 5ª Câmara Criminal do E. TJSP (Ap.990.09.170.228-5 – Des. Rel. Marcos Zanuzzi, v.u. j. 10.12.09). Nesta esteira, atento a natureza e quantidade dos entorpecentes, é que a redução deverá ser feita na proporção de 1/4 (um quarto), perfazendo o total de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Ausentes outras causas modificativas, torno a pena definitiva do réu em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

No que tange ao regime penitenciário, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 11.840/ES, no Pleno, rel. Min. Dias Toffi. Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §2º e 3º do Cód. Penal, bem como do art. 42 da Lei 1.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei (STJ HC 272.152/SP rel. Min. Marilza Maynard 6ª Turma J. 10.12.2013).

Desta forma, ainda em razão da natureza e diversidade das drogas, bem como das circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Ainda que seja do entendimento desta Magistrada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no crime de tráfico de entorpecentes, não vislumbro o preenchimento dos requisitos pelo sentenciado, razão pela qual indefiro a substituição, especificamente ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) acima apontadas.

Sem detração ou progressão neste ato, tanto porque ainda não cumpridos o requisito objetivo (temporal), quanto pelo fato de que ausentes elementos para análise do requisito subjetivo, devendo tal matéria ser analisada pelo juízo competente, ou seja, o das execuções – aliás, como vem entendendo a jurisprudência do E. TJ/SP. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido na ação penal e CONDENO ALMIR ROSNER CAVALHEIRO como incurso no artigo 33, caput, c.c. § 4º, da Lei 11.343/06 à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Nego recurso em liberdade, considerando a manutenção das circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva por necessidade de garantia da ordem pública.

Determino a perda do dinheiro e demais bens apreendidos em favor da União. Proceda-se como de praxe.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que é beneficiário da gratuidade de justiça (advogado nomeado em razão do convênio entre a OAB/SP e a DPE/SP). Expeça-se certidão de honorários, nos termos máximos previstos na tabela de regência.

P.I.C.

Guariba, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA